

1509180-56.2021.8.26.0510

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROGÉRIO LUCIANO SILVA

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Vistos.

ROGÉRIO LUCIANO SILVA, qualificado no inquérito, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

1ª Vara Criminal

Avenida 5 nº 545, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às18h00min

1509180-56.2021.8.26.0510 -
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509180-56.2021.8.26.0510 - 2021/000820

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROGÉRIO LUCIANO SILVA

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Vistos.

ROGÉRIO LUCIANO SILVA, qualificado no inquérito, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c. as disposições da Lei nº 8.072/90, assim porque, no dia 14 de dezembro de 2.021, por volta das 12:47 horas, na Avenida 70, nº 120, Recanto Paraíso, nesta Comarca, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, guardava e tinha em depósito, 25 (vinte e cinco) invólucros plásticos contendo a substância entorpecente denominada cocaína, com peso líquido de 34,15 gramas, 02 (dois) invólucros plásticos contendo a mesma substância, na forma de crack, totalizando peso líquido de 0,67 gramas, e mais 15 (quinze) microtubos plásticos contendo a mesma substância entorpecente, com peso líquido de 4,38 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09, laudo de constatação de fls. 20/22 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 46/47 sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Regularmente notificado, seguiu-se oferecimento de defesa preliminar em favor do acusado, sendo posteriormente recebida a denúncia no dia 07 de março de 2022.

Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, com posterior interrogatório do acusado.

Em alegações finais, a ilustre Representante do Ministério Público, à vista da prova produzida, requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, com fixação da pena-base no mínimo legal, devendo ser majorada em decorrência da recidiva, com o afastamento do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, devendo a pena ser cumprida em regime prisional inicial fechado.

Já ilustre Defensora Pública inicialmente observou que a apreensão do entorpecente decorreu de procedimento ilícito, com invasão de domicílio, comprometendo a materialidade delitiva, a determinar a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. Assim não se entendendo, porque insuficiente a prova produzida, pelas razões que cuidou em expor, requereu a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do mesmo Estatuto Processual Penal. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito irrogado ao acusado para a infração prevista no artigo 28, da Lei de Tóxicos. Em caso de condenação, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal, com o reconhecimento do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, se considerada antes a recidiva, a afastar bis in idem, com a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, facultando-se, por fim, a interposição de recurso em liberdade.

Em síntese, o RELATÓRIO.

DECIDO.

Procede a pretensão acusatória.

Atribui-se ao acusado a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, assim porque, guardava e tinha em depósito, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, o entorpecente indicado na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A materialidade do delito vem comprovada pelo que exposto no laudo de exame químico-toxicológico encartado as fls. 46/47, com resultado positivo para cocaína. Sustenta-se que a materialidade do delito estaria comprometida diante da ilícita apreensão do entorpecente, decorrente de violação de domicílio. Entretanto, respeitado o entendimento exposto, não se entende tenha ocorrido a mácula apontada. Como exposto pelos policiais civis que realizaram a apreensão, na ocasião havia denúncia de que no local estava ocorrendo o comércio ilícito, o que ensejou, como de rigor, uma investigação, constatando-se que no dia dos fatos o acusado manteve contato com um indivíduo que chegou àquele local com uma motocicleta, depositando uma sacola ao chão, junto ao portão, tendo sido possível notar que ele retirou alguns "kits" de entorpecentes e os entregou ao acusado, em seguida deixando o local. Logo em seguida o acusado deixou o imóvel, quando então foi abordado, acabando por admitir que estava guardando o entorpecente no local. Diante desta observação, confirmada a denúncia anteriormente recebida, os Policiais Civis ingressaram no imóvel e efetivamente apreenderam o entorpecente descrito na denúncia.

Deste modo, o ingresso no imóvel se deu em razão da observação inicial, de que por lá estava sendo deixado entorpecente, como também pela confirmação posterior por parte do acusado, revelando estado flagrantial decorrente de crime de natureza

permanente, a excepcionar, portanto, a inviolabilidade do domicílio. Controverte-se igualmente sobre a posse e a destinação mercantil do entorpecente apreendido.

Ouvido em juízo, o acusado negou a prática do delito que lhe é irrogado na denúncia, afirmando que na ocasião tinha ingressado no referido imóvel onde adquiriu o entorpecente, sendo abordado por Policiais Civis quando deixou aquele local, desfazendo-se do entorpecente apreendido. Confirmou que havia mais entorpecente por lá, onde foram efetivamente apreendidas algumas porções de cocaína. Acrescentou que aquele "barraco" era ocupado pelo irmão, que guardava o entorpecente em favor de um indivíduo conhecido por "Boca".

Todavia, a versão deduzida pelo acusado foi contrariada pela prova produzida. De fato, os Policiais Civis ouvidos, reiterando em juízo o que inicialmente exposto, afirmaram que na ocasião dos fatos havia denúncia de que no imóvel referido estava ocorrendo o comércio ilícito de entorpecente. Diante disto iniciaram uma observação no local, a fim de investigar a idoneidade daquela denúncia, constatando-se na época que o acusado manteve contato com um indivíduo que lá chegou com um motocicleta, portando uma sacola, no interior da qual retirou alguns "kits" de entorpecentes e os entregou a ele, em seguida deixando o local. Momentos após, o acusado deixou o imóvel, sendo em seguida abordado. Admitiu que tinha recebido o entorpecente, indicando o local onde acabou sendo apreendido, já no quarto dele, com observação de que o guardava em proveito de terceiro. Como se tem rotineiramente consagrado, à míngua de elemento que demonstre efetivamente algum abuso, não há de se desmerecer o depoimento dos policiais civis envolvidos nas diligências. A propósito: "os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais que oferecem a seus superiores e à justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes" (in Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco e Outros, 3ª ed., RT, p.1829).

Ademais, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54). Acresça-se que "é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (RT 530/372).

E, ainda: "cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva. Não é suficiente a mera alegação por simplesmente serem os depoentes policiais" (Apelação nº 990.09.216746-4, TJSP, Rel. Salles Abreu).

Do que vem de ser exposto, tem-se que havia denúncia anterior de que no local estava sendo realizado o comércio ilícito, não por outro motivo se iniciando a investigação, constatando-se que na ocasião o acusado manteve contato com terceiro indivíduo, que lhe entregou "kits" de entorpecentes, como comumente embalados para o tráfico, os quais foram efetivamente apreendidos, por indicação do acusado, que admitiu inicialmente estava guardando em proveito de terceiro, estas circunstâncias possibilitando seguro juízo de convicção sobre a realidade da imputação inicial. Isto considerado, passo à dosagem da pena.

Considerando o disposto no artigo 59, do Código Penal, e artigo 42 da Lei de Tóxicos, não sendo expressiva a quantidade de entorpecente apreendida, deve a pena-base ser fixada no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em face da recidiva específica (fls. 132/139), a pena-base deve ser agravada em 1/6

(um sexto), totalizando 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, estes no valor unitário mínimo, em razão da situação econômica do acusado.

Por fim, diante do entendimento firmado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, de que não caracteriza ofensa ao princípio do non bis in idem, a recidiva também afasta objetivamente a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e, com fundamento no artigo 33, "caput", Lei nº 11.343/06 e artigo 61, inciso I, do Código Penal, CONDENO o acusado ROGÉRIO LUCIANO SILVA à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, estes no valor unitário mínimo, diante da situação econômica do acusado, corrigido desde a época do fato.

Dada a recidiva e a natureza hedionda do delito, por equiparação, atendendo comando constitucional (art. 5º, XLIII, CF) e o disposto no artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.464/07, deve a pena imposta ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Não se ignora que o regime prisional mais gravoso, por conta da hediondez equiparada do delito, foi também considerado inconstitucional, em caráter incidenter tantum no HC nº 111.464/ES, sendo Relator o Ministro Dias Toffoli, por maioria de votos, entendendo-se padecer do vício de violação ao princípio da individualização da pena, devendo ser fixado o regime prisional, mesmo em se tratando de delitos hediondos e equiparados, na forma do artigo 33, § 2º, alíneas "b" e "c", do Código Penal.

Nada obstante a autoridade da mencionada decisão, prolanada do Pretório Excelso, em controle difuso, reconhecendo incidentalmente a inconstitucionalidade, e considerando a controvérsia que marca a questão, até mesmo no âmbito da Suprema Corte, já que a decisão foi tomada por maioria de votos, possível dizer, com a mais elevada vênia, que em função do comando previsto no artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, cuidou o legislador infraconstitucional em estabelecer tratamento mais rigoroso para o cumprimento da pena de alguns delitos (hediondos e equiparados) dada a maior gravidade da violação aos bens juridicamente protegidos, por isto se estabelecendo no artigo 2º, §1º, da Lei nº 8072/90, com a alteração dada pela Lei nº 11.464/07, que a pena seria cumprida em regime prisional inicial fechado.

Não se entende, renovada a vênia, tenha a disposição legal violado o princípio da individualização da pena, porquanto, não obstante a limitação ao regime inicial mais gravoso, como ocorre em situações outras, dada a valoração legitimamente exercida pela atividade legislativa, tendo como fonte o anseio de se reprovar de forma distinta ações delitivas que causam maior perturbação ao meio social, não se tem por interditada a progressividade no cumprimento da pena, tampouco os benefícios do livramento condicional e a remissão, o que assegura a individualização da sanção, sem descuidar de suas funções retributivas e preventivas, além de ressocializadoras.

Como se tem objetado, se o regime inicial obrigatoriamente fechado é inconstitucional, por conta de critérios qualitativos (crimes hediondos e equiparados), também o seria pelo critério quantitativo da regra prevista no artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal, que prevê obrigatoriamente regime prisional inicial fechado no caso de pena superior a 8 (oito) anos. Além disto, submetendo a individualização da pena em casos de delito hediondo ou equiparado tão somente às regras gerais previstas no artigo 33, §2º, do Código Penal, estar-se-ia retirando eficácia do comando inserto na Constituição Federal que determinou a adoção de tratamento diferenciado mais rigoroso nestas hipóteses (cf. art. 5º, LXIII, CF). Deste modo, a pena cominada ao acusado deverá ser inicialmente cumprida em regime prisional fechado, seja em razão da recidiva seja em função da natureza hedionda do delito, não se lhe facultando a interposição de recurso em liberdade, já que persistem os fundamentos que determinaram a prisão cautelar, potencializados pela sentença condenatória, sem prejuízo de eventual progressão em sede de execução provisória.

A propósito: "O direito de apelar em liberdade de sentença condenatória não se aplica ao réu já preso, desde o início da instrução criminal, em decorrência de flagrante ou de preventiva. A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência (Súmula nº 9, do STJ)" (HC nº 86907/RS, Rel. Min. Felix Fisher, DJU. 14.04.2008, p.1).

E, especificamente aqui, "a apelação em liberdade prevista no art.59 da Lei nº 11.343/06 pressupõe a cumulação dos pressupostos da primariedade e da inexistência de antecedentes com o fato de ter o réu respondido em liberdade a ação penal, tanto pela inoccorrência de prisão oriunda de flagrante delito quanto pela inexistência de decreto de prisão preventiva" (HC - Agr. 94.521/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 1º.08.2008).

E, por fim: "o agente que responde a todo o processo por tráfico ilícito de entorpecente preso não tem o direito de aguardar o recurso interposto pelo Órgão Ministerial em liberdade, mesmo tendo a sentença contra si prolatada substituído a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária e serviços à comunidade, eis que a efetividade imediata da pena substitutiva, configuraria em execução provisória" (TJSP, HC 387.079-3/4, 5ª Câmara, Rel. Des. Gomes de Amorim, v.u., RT807/605, apud RENATO Marcão, Tóxicos, 4ª ed.p.527).

Por fim, diante do quantum da pena aplicada, não incide as disposições previstas no artigo 387, §2º do Código de Processo Penal.

Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra e, oportunamente, promova-se o registro da condenação definitiva no sistema informatizado da serventia, comunicando-se o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (I.I.R.G.D.). Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Rio Claro, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA